

1501172-87.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501172-87.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501172-87.2021.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134062/2021 - DEL.POL.CAPÃO

BONITO, 17964940 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 870/21/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2134062 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HEBERT ALVES DE OLIVEIRA PROENÇA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de HEBERT ALVES DE OLIVEIRA PROENÇA, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta na denúncia (fls. 84-86), no dia 17 de maio de 2021, por volta das 13:30 horas, na Rua Abílio Mendes, nº 452, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca,

HEBERT, tinha em depósito e guardava drogas, consistentes em um tablete de maconha, com massa bruta de 40,55 gramas; um pé (planta) da mesma droga, com massa bruta de 15 gramas; e duas porções de crack, com massa bruta de 3,78 gramas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 14/16 e laudo de constatação preliminar a fls. 17/18). De acordo com o Ministério Público, o endereço em questão era suspeito de funcionar como ponto de venda de drogas ("biqueira"), de modo que a Autoridade Policial representou por busca domiciliar, medida deferida por este juízo nos autos nº 1500342-24.2021.8.26.0123.

Quando do cumprimento da medida cautelar, HERBERT e sua companheira Janaína estavam no imóvel, próximos a duas porções de crack e a uma balança de precisão. Ambos foram contidos para averiguação e, durante as buscas na residência, os policiais encontraram as demais drogas acima descritas, outra balança de precisão e petrechos conjuntamente usados para preparar porções de droga para a venda (pratos, facas, estiletes, papel alumínio, etc.), além de telefones celulares e R\$ 2.105,00 em cédulas de valores diversos. Finalmente, também foi apreendida uma arma de pressão, do tipo pistola, marca Spring P226, importada por Rossi, acondicionada em sua embalagem.

A prova colhida, no entender do Ministério Público, não indicou elementos suficientes que do envolvimento de Janaína com o tráfico, senão sua conivência.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 87-89, seguindo-se a regular citação do réu (fl. 148), com posterior apresentação de resposta à acusação (fl. 151-155).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal em regime diverso do fechado, com redução em patamar máximo de 2/3 pela previsão do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 09-13), auto de exibição e apreensão (fls. 14-16), laudo pericial da balança de precisão (fls. 130-132), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 133-137, 138-141 e 142-146) positivo para maconha e cocaína, e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, vê-se que este foi preso em flagrante delito (fl. 01); e na fase policial, disse que: no dia dos fatos, se encontrava em sua casa, quando policiais informaram que tinham um mandado de busca e apreensão para sua residência; nas buscas, encontraram um pouco de maconha e também uma pedra de crack; as drogas são suas, pois é usuário; nega que realiza o comércio de drogas; não conhece a pessoa de Vanderlei Godoy citada pelos policiais; sobre as balanças de precisão que foram encontradas em sua casa, informa que achou na rua, mas não as utiliza para a finalidade de pesar a droga; em relação ao dinheiro encontrado em casa, quase 2 mil reais, trabalha com reciclagem e o dinheiro é fruto desse trabalho (fls. 07-08)

Interrogado em juízo, disse que: nega os fatos; no dia da prisão estava sentado no

sofá com a esposa; estava preparando um cigarro; as drogas eram para uso pessoal; o dinheiro tinha recebido da mãe e sogra; as balanças, uma achou na rua e a outra a esposa comprou para começar a preparar coxinhas para vender; o dinheiro era para pagar as contas.

A testemunha, Alessandro Corbage de Sá, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é policial civil da unidade de inteligência de Itapeva, na data dos fatos, realizaram diligências neste município, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos nº 1500342-24.2021.8.26.0123 em trâmite na segunda vara criminal desta comarca de Capão Bonito; foi ao endereço situado na Rua Abílio Mendes, 452 e 454 na Vila Aparecida; pelo local encontrou o casal HEBERT e Janaina que estavam no interior da casa, ocasião em que informou o motivo de sua presença; em buscas pela casa encontrou em cima da estante da sala um prato com uma porção de crack, bem como uma faca com resquícios dessa droga, além de uma mini balança de precisão; diante disso ficou responsável por conter os investigados, enquanto outros policiais continuaram as buscas; esclarece que nessas buscas os policiais, localizaram os seguintes objetos e drogas: um tablete de maconha, mais duas pedras de crack, um pé de maconha in natura plantado no quintal da residência, um simulacro de arma de fogo, além de uma grande quantidade de dinheiro cuja origem não foi explicada; diante dos fatos deram voz de prisão ao casal e o apresentaram até a unidade policial para que a autoridade policial deliberasse acerca das providências pertinentes ao caso; por fim, informa que já realizavam uma investigação em desfavor da pessoa de Vanderlei Godoy há cerca de 30 dias, sendo que nessa casa fora observado uma grande movimentação de pessoas típica de "biqueira". (fl. 03).

Em juízo relatou que: o depoente e o parceiro receberam a informação de colaboradores de que o réu estaria comercializando entorpecentes na sua residência; realizaram campanhas na rua em que o réu morava; constataram que muitos indivíduos adentravam na residência, permaneciam por algum tempo, e depois saíam; alguns permaneceriam por considerável tempo, indicando que estava ocorrendo o consumo de drogas no local; solicitaram o mandado de busca e apreensão e encontraram maconha, crack, balança, prato em que a droga era particionada, considerável quantia de dinheiro fracionado; não conhecia o réu previamente aos fatos; quando adentraram a residência o réu estava sentado no sofá, se não se engana, fumando um baseado; optaram por não realizar a abordagem de usuários porque chegaram à conclusão de que estava ocorrendo o consumo no local e porque a região da cidade lá é bastante hostil e a abordagem na rua poderia prejudicar a investigação.

A testemunha, Sílvio Almeida de Oliveira, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é policial civil da unidade de inteligência de Itapeva na data dos fatos, realizaram diligências neste município, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos nº 1500342-24.2021.8.26.0123 em trâmite na segunda vara criminal desta comarca de Capão Bonito; esclarece que já realizavam uma investigação em desfavor do investigado Vanderlei Godoy, sendo que as denúncias iniciais eram no sentido de que ele juntamente com uma pessoa até então desconhecida realizava a venda de droga no endereço situado na Rua Abílio Mendes, 452 e 454 na Vila Aparecida; importante destacar que durante vários dias realizaram campanhas em dias e horários diferentes, sendo possível visualizar uma grande movimentação de pessoas com características de usuários de droga, havendo fortes indícios que no local funcionaria uma "biqueira" pelo local encontramos o casal HEBERT, sendo ele a pessoa que constava das denúncias iniciais e Janaina que estavam no interior da casa, ocasião em que informaram o motivo de nossa presença; em buscas pela casa encontraram em cima da estante da sala um prato com uma porção de crack, bem como uma faca com resquícios dessa droga, além de uma mini balança de precisão; diante disso o policial Alessandro ficou responsável por conter os investigados, enquanto o depoente e outros policiais continuaram as buscas; ato contínuo localizaram os seguintes objetos e drogas: um tablete de maconha, mais duas pedras de crack, um pé de maconha in natura plantado no quintal da residência, um simulacro de arma de fogo, além de uma grande quantidade de dinheiro cuja origem não foi explicada; diante dos fatos deram voz de prisão ao casal e o apresentaram até a unidade policial para que a autoridade policial deliberasse acerca das

providências pertinentes ao caso; por fim, informa que as investigações prosseguem em relação à pessoa de Vanderlei Godoy que não; estava no local, mas é o responsável pelo endereço, juntamente com sua mãe Eni, sendo que oportunamente iremos ofertar relatório dessas outras diligências, incluindo a análise dos aparelhos celulares apreendidos nesta data. (fls. 04-05).

Em juízo relatou que: havia informação de que o réu estaria promovendo o comércio de entorpecentes; passaram a monitorar o local à distância e observaram a movimentação de pessoas que sabiam ser usuários de entorpecentes; representaram pela concessão de mandado de busca e apreensão; localizaram maconha, crack, duas balanças, grande quantidade de dinheiro, frascos com resquícios de entorpecentes; além disso localizaram um rolo de papel alumínio utilizado para embalagem de entorpecentes; as informações iniciais que deram causa à campana diziam que era o réu, juntamente com a esposa e outro indivíduo que está sob investigação; Mateus é de um outro tráfico que investigaram; as informações incluíam Vanderley Godoy também estava participando; Vanderley já foi preso por tráfico de entorpecentes; parte do entorpecente estava na estante na sala em que eles estavam sentados no sofá; no quarto do casal encontraram parte do dinheiro, a balança e os demais objetos relacionados com o tráfico; a princípio alegaram ser usuários; não conhecia o réu antes da ocasião; não havia outras denúncias; conhecia apenas a partir das denúncias que motivaram a investigação;

A testemunha, Janaína Antunes Ribeiro, companheira do denunciado, em solo policial, disse que: não realiza o comércio de drogas; policiais na data em questão foram até sua casa para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão e encontraram droga tipo maconha e crack; tais drogas pertencem ao meu marido HEBERT que é usuário; esclarece que ele também não realiza o comércio de drogas; nada sabe dizer sobre as balanças e demais insumos encontrados em sua casa; ressalta que a pessoa de Vanderlei Godoy é filho da dona da casa onde moram, sendo que alugaram tal casa; não tem o conhecimento que ele está envolvido com o comércio de drogas (fl. 06).

A testemunha da Defesa, Natieli Cristina Lara, disse não ter conhecimento do envolvimento do réu com drogas e nem ter visualizado nenhum movimento estranho na residência dele; a depoente mora próximo ao réu e aluga casa da mesma pessoa que ele; sempre via o réu coletando reciclagem na rua; não sabe se o réu era usuário de entorpecentes; a depoente trabalha em casa; não sabe de problemas do réu com a polícia civil; só conhece o réu de vista mesmo.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados

de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que a Polícia Judiciária vinha recebendo denúncias da realização do tráfico de entorpecentes no endereço do réu e apontando HEBERT como sendo traficante. Após as diligências iniciais consistentes na realização de campana, verificaram movimentação típica do comércio de entorpecentes, com a entrada e saída de pessoas. Essas pessoas ora entravam e saíam rapidamente, como disse Silvio ou, algumas vezes, permaneciam no local por certo tempo, indicando, como disse Alessandro, o consumo de entorpecentes no local.

Diante disso, a Polícia Judiciária solicitou a concessão de mandado de busca e apreensão. A medida foi autorizada por este juízo nos autos em apenso (nº 1500342-24.2021.8.26.0123) e, em cumprimento, localizaram os entorpecentes indicados no auto de exibição e apreensão de fls. 14-15 (um tablete de maconha, com massa bruta de 40,55 gramas; um pé (planta) da mesma droga, com massa bruta de 15 gramas; e duas porções de crack, com massa bruta de 3,78 gramas).

Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão, papel alumínio, um prato com resquício de entorpecentes, duas facas com resquícios de entorpecentes, um pequeno prato de vidro, igualmente com resquícios.

De acordo com o laudo pericial de fls. 204-210, havia resquícios de drogas nos objetos apreendidos na casa do réu (faca, rolo de plástico, rolo de papel alumínio, cinzeiro, prato) comprovando a utilização dos objetos para o preparo de entorpecentes.

Ainda que o réu negue o comércio de entorpecentes, o relatório policial relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 62-68) aponta conversa de HEBERT com Matheus compatível com a referência aos entorpecentes. HEBERT avisa ao seu interlocutor que algo chegou, que "tá teno", ao passo que Matheus informa que iria para lá ("to colando"). Em outro dia, Matheus pede para HEBERT separar mais 25 (ou porções ou gramas de entorpecentes).

Uma conversa com outro interlocutor, Edu, que indaga quanto conseguiriam enviar para uma terceira pessoa, HEBERT afirma que está ele ficará satisfeito, porém não tinha "eskanke" (skank é um tipo de maconha). Edu, ao que as conversas indicam, forneciam drogas para HEBERT. Na conversa às fls. 67 Edu menciona querer mandar "logo 10" para HEBERT "trabalha sossegado".

Quanto ao dinheiro apreendido, o réu inicialmente disse ser produto de seu trabalho como coletor de recicláveis e, posteriormente, afirmou ter ganho de sua mãe e sogra para o pagamento das contas. Nenhuma delas foi trazida a juízo para confirmar essa informação, entretanto.

Considerando os depoimentos das testemunhas dando conta do recebimento de denúncias de que o réu estava traficando entorpecentes; a realização de campanas constatando o movimento típico de ponto de venda de drogas; a apreensão de drogas na residência do réu; a localização de duas balanças de precisão, além de outros petrechos com sinais de utilização para o particionamento de drogas; as conversas no telefone do réu com conteúdo relacionável ao tráfico, há provas suficientes de autoria e materialidade do delito a justificarem a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu, de forma consciente e espontânea, tinha em depósito e guardava drogas, consistentes em um tablete de maconha, com massa bruta de 40,55 gramas; um pé (planta) da mesma droga, com massa bruta de 15 gramas; duas porções de crack, com massa bruta de 3,78 gramas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Com isso, resta preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da

antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu HEBERT ALVES DE OLIVEIRA PROENÇA nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida maconha e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos um tablete de maconha, com massa bruta

de 40,55 gramas; um pé (planta) da mesma droga, com massa bruta de 15 gramas; e duas porções de crack, com massa bruta de 3,78 gramas. O montante já revela maior reprovabilidade.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juiz sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, tendo em vista que as circunstâncias descritas no art. 42, da Lei 11.343/06 e 59, do Código Penal, somadas, totalizam dez distintas, a serem valoradas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceu-se uma circunstância como negativa (a natureza e quantidade das substâncias), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de reclusão 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se não constarem quaisquer das situações ou circunstâncias previstas nos arts. 65 e 66, do Código Penal, nem daquelas elencadas nos arts. 61 e 62, do mesmo diploma, razão pela qual mantenho a pena provisória tal como fixada.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Pelas

circunstâncias em que se deu a prisão do réu há evidências de que vem se dedicando reiteradamente à traficância, fazendo do comércio espúrio seu meio de vida. Veja-se os petrechos apreendidos indicando o preparo da drogas, as embalagens, facas, balança de precisão, e mais de dois mil reais em espécie proveniente da atividade ilícita. Não se aplica, assim, a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Torno definitiva a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 7 anos de reclusão), o fato do réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP, sendo negativa a natureza e a quantidade do entorpecente), a pena deverá ser cumprida em regime fechado.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena superior a 4 anos, não satisfazendo o requisito objetivo para a substituição ou para o sursis.

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.4 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação

0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu HEBERT ALVES DE OLIVEIRA PROENÇA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-multa com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

O réu foi preso com considerável quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) e as evidências dos autos comprovam que ele vinha se dedicando, como meio de subsistência, ao comércio ilícito. Assim, entendo que a necessidade de por fim à traficância por parte do réu justifica a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se a guia de recolhimento provisório. Recomende-se a manutenção da custódia cautelar.

4.2 Fixação do valor mínimo para reparação do dano

O tráfico de drogas tem como vítima toda a coletividade. Não há, portanto, dano a ser reparado.

4.3 Decretação de perdimento dos bens

Nos termos do art. 63, I, da Lei de Drogas e art. 91, II, b, do Código Penal, DECRETO o perdimento da quantia apreendida com o réu (depositado às fls. 60), bem como da espingarda de pressão e dos telefones celulares, por serem produto do crime.

4.4 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA